

1501472-13.2022.8.26.0544
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Renata Marques de Jesus
Comarca: Francisco Morato
Foro: Foro de Francisco Morato
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 18/10/2022
... Superior Tribunal de Justiça:

"DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Francisco Morato
Foro de Francisco Morato
1ª Vara
Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato - SP - cep 07910-220
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501472-13.2022.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501472-13.2022.8.26.0544
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
TIAGO DO NASCIMENTO MARQUES

RÉU PRESO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Marques de Jesus

Vistos.

TIAGO NASCIMENTO MARQUES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06, porque no dia 05 de junho de 2022, por volta das 11h30, na Osório Duque Estrada, nº 84, Vila Santo Antônio, cidade e Comarca de Francisco Morato, trazia consigo, para fins de tráfico, 383 (trezentos e oitenta e três) porções de "maconha" (cannabis Sativa L.), com peso líquido aproximado de 1.195,3g (mil, cento e noventa e cinco gramas e três decigramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (1/3).

Em audiência de custódia foi convertida em preventiva a prisão em flagrante (fls. 34/35).

Notificado, o réu apresentou defesa prévia (fls. 80/81) e a denúncia foi recebida (fls. 82/84). Citação às fls. 108/109.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas (fls. 119/120) e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 121). Mídias arquivadas.

Em debates o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido nos termos da denúncia, observando a reincidência específica, a justificar imposição de regime inicial fechado, e a impossibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da lei nº 11.343/06 (fls. 116/118). A Defesa, por sua vez, em memoriais requereu a absolvição com base no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28, do SISNAD (fls. 125/128).

É o relatório.
Fundamento e decido.

À luz das provas carreadas aos autos, a pretensão inicial merece prosperar. A materialidade restou comprovada ante o auto de prisão em flagrante (fls. 4/8), boletim de ocorrência (fls. 9/11), auto de exibição e apreensão (fls. 15), laudo de constatação provisória (fls. 20/23), além do exame químico-toxicológico de fls. 110/112, que constatou a presença de tetrahydrocannabinol (THC) na amostra analisada e do laudo de objeto de fls. 113/115.

A autoria também é certa.

Na fase extrajudicial o réu negou a prática do delito, narrando que é usuário de drogas e, por ocasião dos fatos, havia acabado de comprar entorpecente para uso próprio, sendo abordado. Negou, também, que a sacola localizada lhe pertencia (fls. 8). Em juízo disse ter 30 anos de idade, ter um filho menor, morar em casa própria, trabalhar como servente de pedreiro, com renda aproximada de R\$ 80,00 por semana, não conhecer as testemunhas arroladas, que nunca o abordou, e já ter sido processado por tráfico e furto. Sobre os fatos declarou que foi no local comprar droga. Os traficantes disseram para pular o muro, pois estava cheio de policial. Eles estavam servindo no mato. O policial pulou o muro e escutou o traficante gritando "perdi senhor", mas ele conseguiu fugir. Consigo tinha uma pedra de crack, "um bombril e um caninho". Não tinha dinheiro. Tinha apenas R\$ 5,00 para comprar sua droga. Estava pulando o muro para ir embora. Não tinha rádio comunicador, nem usava blusa de moleton. Não tinha maconha (fls. 121).

Linco Barbosa Ortiz, policial militar que participou da ocorrência, afirmou que realizava patrulhamento de rotina com seu colega de farda quando passaram pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de droga, e avistaram um indivíduo próximo ao muro, e este ao ver a viatura se evadiu do local. Se dirigiram ao local de onde tal indivíduo estava e ao lado do muro, avistaram um indivíduo posteriormente identificado como sendo o réu, que estava escalando o muro onde iria servir a droga para eventuais usuários, e em suas mãos foram encontrados 02 (duas) unidades de uma substância esverdeada aparentando ser "maconha" e em seu bolso, 04 (quatro) unidades da mesma substância, além de 01 (um) rádio comunicador. Realizando buscas pelo local, encontraram uma sacola contendo 377 (trezentos e setenta e sete) unidade da substância esverdeada aparentando ser "maconha". Indagado o réu este disse que era usuário de droga e estava ali para adquirir maconha para seu consumo (fls. 5). Em juízo, confirmando suas declarações, relatou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas. Em patrulhamento viram um indivíduo próximo ao muro, em um terreno baldio, onde normalmente há o tráfico. Ao perceber a chegada da viatura fugiu. O réu subiu o muro para servir esse suposto usuário e foi abordado. Na mão dele tinha 2 trouxas de maconha. No moleton dele mais quatro porções e um rádio comunicador. Do outro lado do muro tinha uma sacola com mais maconha. Ele disse estar no local por ser usuário. Já o tinha abordado em outra oportunidade, mas foi liberado. Ninguém mais estava no local. A sacola estava do lado do muro onde estava o réu e as drogas que estavam dentro eram as mesmas e da mesma

embalagem que aquelas encontradas com o acusado. Não viu o réu no momento, pois eles se comunicam por um buraco no muro. Tiago era o "vapor", aquele que vende a droga, e não conseguiu ver a aproximação da viatura e por isso não fugiu. Confirmou que ele estava com o radio comunicador (fls. 119).

Na mesma esteira o depoimento extrajudicial do também policial militar Wanderson Rodrigo Melin (fls. 7), informando em juízo que em patrulhamento de rotina junto com seu parceiro avistou um indivíduo próximo ao muro. Com a aproximação esse indivíduo empreendeu fuga. Foram até o muro e o réu veio até o muro, colocou as mãos para subir e entregar o entorpecente para a pessoa que correu. Ele foi pego e na mão dele tinham 2 trouxas de maconha. No bolso dele mais 4 trouxas e o radio comunicador. Ele negou a traficância e disse ser usuário. Do outro lado do muro tinha uma sacola com mais droga. A sacola estava do lado do muro em que estava o acusado. Na sacola tinha só maconha, embalada da mesma maneira que aquela encontrada com Tiago. Já tinha abordado o réu antes, mas o liberado. Não acompanhou o depoimento da testemunha Linco (fls. 120).

A lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade. Há de se levar em conta que o acusado e os policiais não se conheciam até então, de forma que estes não tinham motivos para acusá-lo leviana e gratuitamente:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte" (STJ, Sexta Turma, AgRg no Ag 1158921/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julg. 17/05/2011, DJe 01/06/2011);

"O depoimento de policial obedece os mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional" (TJSP, RT 752/586);

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/02/97, DOU de 11/04/97, p. 189);

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (TJSP, RT 614/275);

"Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica e não

genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e demonstrada em cada caso" (TJMG, RT 604/407).

A partir do contexto probatório extrai-se que as testemunhas prestaram depoimentos coesos e convergentes, reafirmando as declarações prestadas na fase policial, tornando seguro um decreto condenatório.

E, não demonstrou a Defesa eventual motivo que os policiais militares teriam para mentir em juízo deixando, assim, de se desincumbir de seu ônus (artigo 156, do Código de Processo Penal), destacando que eventuais e pequenas contradições entre os depoimentos, sequer existentes na hipótese, não são capazes de infirmar a lisura do trabalho policial. Nesse sentido:

"PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato" (TACrimSP - Ap. nº 583.153/2 - 7ª Câm. - Rel. José Habice - J. 05.04.90 - RJDTACRIM 6/78).

A Defesa tenta, em vão, diminuir o valor dos depoimentos dos policiais, o que não se sustenta diante do quadro probatório existente e dos elementos de convicção formados. Nesse ponto, é preciso ficar claro que a inexistência de testemunhas civis e 'eventuais compradores' no ato da prisão em flagrante não o invalida, cumprindo ressaltar que em delitos da espécie, como cediço, ainda que populares presenciem a atividade criminosa, estes não querem se identificar com medo de represálias por parte dos criminosos.

Dentro desse quadro, os depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, repita-se, foram harmônicos e convergentes, levando à certeza da autoria.

Sendo assim, a quantidade e nocividade da droga apreendida, a forma como embalada, o fato de o local da apreensão ser conhecido dos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, o fato de o acusado portar rádio comunicador, bem como o depoimento seguro prestado pelas testemunhas, levam à certeza de que o réu traficava drogas na ocasião.

Destaca-se que o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que as simples condutas do réu, consistentes em "trazer consigo" e "ter em depósito" as substâncias entorpecentes, já são suficientes para caracterização do delito:

"Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para esta destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJSP - Apel. Crim. nº 990.09.088010-4 - 5ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 03.09.09 - Rel. Des. Pinheiro Franco).

No mesmo sentido:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663);

"Não é indispensável à prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (RT 729/542);

"Cabe ressaltar que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da prisão para evidenciar tal atividade ilícita". (TJ/SP - Apel. Crim. nº 990. 09.235417-5 - 14ª Câmara Criminal - v.u. - j. 11.03.10 - Rel. Des. Fernando Torres Garcia).

Ressalta-se que a considerável quantidade de entorpecente, além da forma como se deu sua apreensão demonstram a traficância e não autorizam a pretendida desclassificação da conduta como simples consumo pessoal (artigo 28, da Lei nº 11.343/06):

"DESCCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO - Inadmissibilidade - Quantidade e diversidade de entorpecentes - Conjunto probatório suficiente para ensejar o decreto condenatório - Inexistência de prova segura que autorizasse decretar nova definição jurídica da conduta." (TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.08.080898-2, Des. Rel. Leonel Costa, j. 28/04/09).

E o fato de o acusado afirmar que é usuário de droga não é suficiente para a desclassificação do delito de tráfico, sendo, repita-se à exaustão, a condenação de rigor. Vale destacar, ainda, que a condição de usuário não é incompatível com a de traficante:

"(...) a mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra." (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP RJTJSP 101/498);

"Importante consignar que o fato de o acusado ter declarado que era usuário de drogas não afasta sua condição de traficante, uma vez que os usuários, frequentemente, também passam a comercializar entorpecentes, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não exclui a outra" (TJSP; 9.ª Câmara Criminal, Ap. n.º 0001866-59.2015.8.26.0635, Rel. Sérgio Coelho, j. em 31.03.2016);

"Nenhuma incompatibilidade existe entre o tráfico de entorpecente e o vício. Ao contrário. Em regra, vivem associados" (RT 411/104).

Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de não desprezível quantidade de substância entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar separada em unidades diferentes ou dividida em porções, conduz à segura conclusão de que se destina ao comércio ilícito e não ao uso próprio.

Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade, inexistindo causa de exclusão da ilicitude, a ação penal é procedente, amoldando-se a conduta praticada pelo réu à figura típica prevista no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena:

Sopesados os elementos norteadores do art. 59, do Código Penal e em observância ao

disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, que autoriza que o magistrado considere na primeira fase de dosimetria a natureza do entorpecente, a quantidade, a personalidade e a conduta social do agente, de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal (v.g. STF, HC nº 96.655, rel. Min. Cármen Lucia; STF, HC nº 107.784, rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, HC nº 237.837, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC nº 235.524, rel. Min. Jorge Mussi; STJ, HC nº 223.447, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC nº 179.086, rel. Min. Gilson Dipp). No mesmo sentido:

"REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1. Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas. 2. Na espécie, a reprimenda de piso acima do mínimo legal, em razão da natureza e a excessiva quantidade do estupefaciente apreendido, encontra-se devidamente justificada e proporcional às especificidades do caso versado. [...] 2. Agravo regimental a que se nega provimento." AgRg no AREsp 585.375/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017);

O réu é reincidente específico, agravante que será analisada em fase própria, e, na hipótese dos autos, foi localizado com grande quantidade de maconha, o que enseja maior reprimenda, uma vez que maior é o perigo em relação à saúde pública.

Segundo o entendimento de Guilherme de Souza Nucci, "A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua utilização. Estes fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado" (in Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 378)

No mesmo sentido, defende Renato Brasileiro de Lima que "Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela" (in Legislação criminal especial comentada, 2ª edição, JusPODIVM, 2014, p. 787).

Desta feita, por trazer maiores danos à saúde pública, de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por ser proporcional à quantidade do entorpecente apreendido.

Assim, ponderando tal circunstância (quantidade), fixo a pena-base com o acréscimo de 1/6 (um sexto), ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto à fração a ser aumentada, vale destacar não haver previsão legal valorando o quantum, ficando a critério do magistrado analisando o caso concreto: "o magistrado fixa a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STJ, AgRg no REsp nº 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).

Prosseguindo, nos termos do artigo 68, do Código Penal, verifico a ausência de qualquer circunstância atenuante que possa ser aplicada no caso concreto. Faz-se presente, todavia, a agravante da reincidência específica (art. 61, I, do Código Penal), inferindo-se da folha de antecedentes e certidão (fls. 28/33) que o réu foi condenado nos autos nº 4021-88.2015.8.26.0197, junto à 2ª Vara local, pelo crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), estabelecendo-a em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa. Justifica-se o aumento da agravante acima do mínimo em razão da reincidência específica, mesmo única, impondo-se tratamento diferenciado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo. II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada” (STF HC nº 101918/MS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 11/05/2010);

“A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)” (STJ HC nº 257.571/SP Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma DJe 18/02/2014).

Na terceira fase não é o caso de incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ou seja, do reconhecimento do crime de “tráfico privilegiado”.

Restou demonstrado que o réu trazia consigo elevada quantidade de entorpecente (mais de 1 quilo de droga), a indicar um acentuado envolvimento no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta. Além disso, não demonstrou o exercício de atividade lícita. Quadro, pois, a desnudar que se trata de pessoa dedicada às atividades criminosas.

E, como se destacou, o réu é reincidente específico, tendo sido recentemente condenado nos autos sob nº 4021-88, pelo mesmo crime de tráfico de drogas (fls. 32/33).

Enfim, havendo indícios do envolvimento do acusado com a criminalidade, descabido o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, valendo trazer à colação, como já se decidiu, que a conduta social do réu, a quantidade e a natureza do entorpecente, além das circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa (RHC nº 116.926/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. em 20.8.2013; HC nº 116.541/ES, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6.6.2013; HC nº 98.366/MG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.2.2010).

Nesse sentido o C. Superior Tribunal de Justiça:

"DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. No caso em análise, com base na grande quantidade de drogas apreendidas, as instâncias ordinárias concluíram que o paciente dedica-se à atividade criminosa. 3. "Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa" (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018). 4. Embora a quantidade de entorpecentes apreendidos já tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria penal, para exasperar a pena-base, nada impede que tal circunstância seja novamente considerada na terceira etapa, para aferir a traficância habitual e, conseqüentemente, obstar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006." (AgRg no HC 499936 Rel. Min. Jorge Mussi julg. 25/06/2019 publ. 01/07/2019)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. AGENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO CRIMINAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APLICAÇÃO DA NORMATIVIDADE REGENTE. QUANTUM DE PENA A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) VI - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja, "670 g de maconha". Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional" (Quinta Turma, AgRg no HC 548913/MS. Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo. Julgado em 10/03/2020. DJe 18/03/2020)

Esta pena torna-se definitiva, tendo em vista a inexistência de outras causas de aumento e de diminuição.

O valor do dia-multa deve ser calculado nos termos do artigo 43, da Lei nº 11.343/06, sendo fixado em um trinta avos do salário mínimo vigente à época do pagamento, tendo em vista a situação econômica do acusado.

O tráfico de entorpecentes é crime gravíssimo, pois pressupõe violência e grave ameaça à sociedade, principalmente por atingir a sua população mais jovem e vulnerável, aumentando os índices de criminalidade, desestruturando cada vez mais famílias e trazendo danos de toda sorte aos envolvidos, tendo o traficante a intenção de levar ao vício o maior número possível de vítimas.

Além disso, não se pode olvidar a natureza da infração e os males que ela provoca no seio social, devendo o infrator experimentar repercussões objetivas acerca da censurabilidade de sua conduta, razão pela qual o réu deverá cumprir sua pena em regime inicialmente fechado:

"TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo

ou equiparado iniciam-se no regime fechado. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; 6ª Câmara de Direito Criminal; AP 0057527-71.2011.8.26.0050; Relator Marco Antonio Marques da Silva, data do julgamento: 27/06/2013).

Vale lembrar que embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90 (HC 111.840/ES), a r. decisão não foi unânime e foi feita de forma incidental, não possuindo eficácia erga omnes e nem efeito vinculante.

E, não sendo o caso de reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, conforme justificado, não há que se falar em aplicação da determinação proferida no Habeas Corpus Coletivo nº 596.603/SP, do C. Superior Tribunal de Justiça (Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz), que determinou a fixação do regime aberto em relação aos presos que "se encontrem na mesma situação (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses, em regime fechado)", estabelecendo, dentre outras determinações, que "aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena" (grifo nosso).

As condições pessoais do réu não são idênticas às daqueles para os quais se determinou a concessão de regime inicial aberto.

Ainda, afigura-se, descabido falar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou "sursis", porque não recomendáveis (artigos 44, I, III, e 77, II, do Código Penal).

Impossível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, diante do montante da pena, da reincidência e também da gravidade concreta do delito, tendo em vista a quantidade das drogas apreendidas, somando um total líquido aproximado de 1195,3g, o que justifica a não substituição da reprimenda (STJ, Quinta Turma, HC 24914/SP, Rel. Min. Marilza Maynard, j. 14/04/2013) :

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - 11,2G DE COCAÍNA, 179,1G DE MACONHA E 554ML DE LANÇA-PERFUME - PENAS - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "j" - IMPOSSIBILIDADE - O NECESSÁRIO ISOLAMENTO SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS GARANTIU, POR INFELIZ VIA TRANSVERSA, O ANONIMATO E A IMPUNIDADE DE USUÁRIOS E TRAFICANTES - AGRAVANTE MANTIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA A INDICAR QUE O ACUSADO, CONQUANTO PRIMÁRIO, FAZ DO TRÁFICO SEU MEIO DE VIDA - REGIME FECHADO ADEQUADO - EVENTUAL ABRANDAMENTO NÃO SERIA SUFICIENTE PARA ATENDER AO ASPECTO QUALITATIVO DA PENA - IMPROVIMENTO DO RECURSO" (TJSP; Apelação Criminal 1514354-53.2020.8.26.0228; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 19/10/2020) - grifos nossos

Ademais, tais benefícios são incompatíveis com a finalidade da Lei nº 8.072/90, que dá tratamento mais rigoroso aos chamados crimes hediondos e assemelhados e que prevê, dentre outras hipóteses, a fixação de regime inicial fechado para cumprimento da sanção imposta ao protagonista de delitos deste jaez.

Pelo mesmo motivo e diante da persistência dos requisitos que mantiveram a prisão cautelar durante o curso do processo, o acusado não poderá recorrer em liberdade. Assim, deverá manter-se recolhido para poder recorrer, até porque seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou:

"(...)6. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (...)"(STJ, HC 449692/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado 23-08-2018).

Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se na prisão em que se encontra, bem como guia de recolhimento provisória, encaminhando-a, com as peças obrigatórias, ao Juízo da Execução competente.

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar TIAGO DO NASCIMENTO MARQUES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.

Em observância ao disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, verifico que o réu encontra-se preso preventivamente a pouco mais de três meses, contudo, não há elementos nos autos - principalmente os subjetivos - para eventual colocação em regime mais benéfico, que fica condicionada à demonstração de que ostenta bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, bem como à verificação de que não se encontra preso, provisória ou definitivamente em razão de outro processo.

Eventual progressão, portanto, quando cabível, deverá ser verificada em sede do Juízo das Execuções Criminais, a ele competindo proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos artigos 66, III, "a" e 111, ambos da Lei nº 7.210/84:

"Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria." (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 - Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Com efeito, como acima fundamentado, respondeu ao processo preso, sendo certo que persistem e nesta sentença são reforçados os requisitos e pressupostos da prisão cautelar.

Autorizo a incineração das drogas, nos termos dos artigos 50, §§ 3º e 4º e 72, ambos da Lei de Tráfico, destruindo-se amostras guardadas para contraprova. Comunique-se nos termos dos art. 524-A, § 2º, e 525, das NSCGJ, caso tal providência ainda não tenha sido adotada.

Decreto o perdimento do objeto apreendido (fls. 15). Oficie-se para a destruição.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, condenado, o réu arcará com as custas processuais:

"o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei 1.060/50. Precedentes. A isenção

somente poderá ser concedida ao réu na fase da execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação" (REsp. 400.682, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 17/11/ 2003,). No mesmo sentido: REsp. 262.961, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 17.06/2002; REsp. 263.021, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 18.03/2002 e REsp. 81.304, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 14/09/98. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso." – grifos nossos (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0008903-30.2009.8.26.0189, Relator Des. Euvaldo Chaib)

Expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado nos autos (fls. 78), nos termos da tabela DPE/OAB vigente.

Após o trânsito em julgado oficie-se ao TRE, para fins do disposto no artigo 15, III da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva e arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.

P.I.C.

Francisco Morato, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA